

人力资源社会保障部关于执行《工伤保险条例》若干问题的意见

作者：谢严兴（劳达集团）

发布日期：2016.05.12

【编者按】

2016年3月28日人力资源社会保障部发布实施了《关于执行《a href=“../document/show?title=&id=MTAwMDU1NTA0MjM%253D”>工伤保险条例》若干问题的意见（二）》（以下简称《若干问题的意见（二）》），针对《工伤保险条例》在司法实践中存在的诸多实务问题，做出了进一步规定和界定，我们在此进行逐条评价和分析，抛砖引玉，仅供交流探讨。

1 一级至四级工伤职工死亡，其近亲属同时符合领取工伤保险丧葬补助金、供养亲属抚恤金待遇和职工基本养老保险丧葬补助金、抚恤金待遇条件的，由其近亲属选择领取工伤保险或职工基本养老保险其中一种。

劳达解读

一般来说，因工死亡和非因工死亡的社保待遇不会出现竞合的情形，但是在一些特定的情形下，则会出现。

根据《工伤保险条例》第三十九条第三款规定：“一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其近亲属可以享受本条第一款第（一）项、第（二）项规定的待遇。”（编者注：此处第（一）、（二）项所规定的待遇，分别是指“工伤保险丧葬补助金”和“工伤保险供养亲属抚恤金”）；同时，《社会保险法》第十七条规定“参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金；。所需资金从基本养老保险基金中支付。”

从法的位阶上看，由全国人大常委会制订并实施的《社会保险法》，其效力高于国务院颁布实施的《工伤保险条例》。那么若一级至四级伤残职工在停工留薪期满后有可能由于非工伤的疾病、特别是在办理病退、退休后再死亡的，那么依据法律效力更高的《社会保险法》，其亲属只能获得《社会保险法》第十七条规定的待遇。

需要注意的是《工伤保险条例》第三十九条第三款所规定的“丧葬补助金和供养亲属抚恤金”的计算方式相对明确，“工伤保险丧葬补助金”计算标准为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；“工伤保险供养亲属抚恤金”的计算标准按“不超过因工死亡的职工本人工资的一定比例”按月发放；而《社会保险法》

第十七条的规定并未明确计算方式，而是交由各地方自行规定，这就造成各地非因工死亡待遇的差异化、且待遇计算标准不透明的情况。例如按深圳市地方规定，非因工死亡的丧葬补助费为死亡时深圳市月平均工资的3倍。一次性抚恤金为死亡时深圳市上年度月平均工资的6—12倍（视受抚恤人数而定）。这个标准远远低于《工伤保险条例》[第三十九条第三款](#)所规定待遇标准。笔者还曾经见到过广东省东莞市虎门镇当地社保部门核算的一份“非因工死亡待遇标准”，核定的总金额合计不足2万元。

还有一个差异化的情况是：依据《工伤保险条例》[第三十九条第三款](#)所规定待遇之一“工伤保险供养亲属抚恤金”是按月发放；而依据《社会保险法》[第十七条](#)的规定支付的待遇为一次性发放。

因此从上述读解和分析不难看出，在“一级至四级工伤职工死亡，其近亲属同时符合领取工伤保险丧葬补助金、供养亲属抚恤金待遇和职工基本养老保险丧葬补助金、抚恤金待遇条件”时，给予近亲属选择领取工伤保险或职工基本养老保险其中一种，是对于近亲属可获得待遇的优待。因此，本条款的规定，是赋予职工近亲属选择权，而选择的结果一般是‘就高不就低’。

当然，当然这种选择也有赖于社保经办机构内部建立待遇台账，防止近亲属利用政府办事程序的漏洞实现“双重领取”的弊端。

2 达到或超过法定退休年龄，但未办理退休手续或者未依法享受城镇职工基本养老保险待遇，继续在原用人单位工作期间受到事故伤害或患职业病的，用人单位依法承担工伤保险责任。

用人单位招用已经达到、超过法定退休年龄或已经领取城镇职工基本养老保险待遇的人员，在用工期间因工作原因受到事故伤害或患职业病的，如招用单位已按项目参保等方式为其缴纳工伤保险费的，应适用《工伤保险条例》。

劳达解读

长期以来，在司法实践中，针对已达到或超过法定退休年龄职工的受到事故伤害或患职业病如何处理的问题，存在很大争议。一部分观点认为，根据《劳动合同法实施条例》[第二十一条](#)规定：“劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止”。既然双方的劳动合同即已终止，那么就不存在劳动关系了，而工伤认定和工伤保险待遇是基于劳动关系基础上的法律关系和法定待遇，因此，在劳动者达到或超过退休年龄后，即使双方延续存在有用工关系，也应当属于劳务关系，故不应被认定为工伤，不应享受工伤保险待遇，而应按人身损害赔偿的法律规定给予救济。

另一种观点认为，劳动关系不必然与工伤保险关系相关联，两者可以进行适当的分离对待。比如，广东省高级人民法院和广东省劳动仲裁委于2012年6月联合发布的《[关于审理劳动人事争议案件若干问题的座谈会纪要](#)》规定：“发包单位将建设工程非法发包给不具有用工主体资格的实际施工人或者承包单位将承包的建设工程非法转包、分包给不具有用工主体资格的实际施工人，实际施工人招用的劳动者请求确认其与具有用工主体资格的

发包单位或者承包单位存在劳动关系的，不予支持，但社会保险行政部门已认定工伤的除外”。从该规定来看，即使发包单位（或承包单位）与劳动者之间不存在劳动关系，也依然可能会支持工伤认定和工伤保险待遇。

2013年4月人社部发布的《[关于执行〈工伤保险条例〉若干问题的意见](#)》[人社部发（2013）34号]吸收了广东省高院的观点，该意见第七条规定：“具备用工主体资格的承包单位违反法律、法规规定，将承包业务转包、分包给不具备用工主体资格的组织或者自然人，该组织或者自然人招用的劳动者从事承包业务时因工伤亡的，由该具备用工主体资格的承包单位承担用人单位依法应承担的工伤保险责任”。上述规定较之广东省的规定走得更远，广东省的规定仅限于建设工程领域，而人社部的规定则扩大为一切实行承包的领域，显然，该规定将劳动关系与工伤保险关系相分离之路越拉越大了。

本次颁布的《若干问题的意见（二）》针对已达到退休年龄职工的能否享受工伤保险问题，分两种情况做出了规定：一种情况是，达到或超过法定退休年龄，但未办理退休手续或者未依法享受城镇职工基本养老保险待遇，继续在原用人单位工作期间受到事故伤害或患职业病的，用人单位依法承担工伤保险责任。另一种情况是，用人单位招用已经达到、超过法定退休年龄或已经领取城镇职工基本养老保险待遇的人员，在用工期间因工作原因受到事故伤害或患职业病的，如招用单位已按项目参保等方式为其缴纳工伤保险费的，应适用《[工伤保险条例](#)》。

关于第一种情况，是指劳动者在达到退休年龄之前，已经在用人单位持续工作，而在达到或超过退休年龄后，用人单位未与该劳动者办理退休手续，或因劳动者未能连续缴纳15年的养老保险而导致其无法享受退休金待遇的，在此期间劳动者受到事故伤害或患职业病的，用人单位须承担工伤保险待遇。此条款给企业敲响了警钟，提醒企业在员工已达到退休年龄时，应当及时办理退休手续，终止双方的劳动合同关系，否则，一旦员工遭遇事故伤害或职业病危害，企业将依法承担工伤保险责任。

此外本条款规定情况实际上是对《[最高人民法院行政审判庭关于超过法定退休年龄的进城务工农民因工伤亡的，应否适用〈工伤保险条例〉请示的答复](#)》（（2010）行他字第10号）做的进一步扩大，适用范围从进城务工农民工扩大到全体职工，实现对“达到或超过法定退休年龄人员”的最大保护（上述司法解释的详细内容，可参见前文摘录）。

关于第二种情况，是指用人单位招用已经达到退休年龄或已享受养老保险待遇的人员，如果单位已按项目参保等方式为其缴纳工伤保险费的，应适用《[工伤保险条例](#)》，反之，如果未参保缴纳工伤保险费，则不适用《[工伤保险条例](#)》，应当按人身损害赔偿法律规定给予救济。以项目方式参保的范围，是指依据人社部《[部分行业企业工伤保险费缴纳办法](#)》（人力资源社会保障部令第10号），主要包括建筑、服务、矿山等行业中难以直接按照工资总额计算缴纳工伤保险费的建筑施工企业、小型服务企业、小型矿山企业。

3 《工伤保险条例》第六十二条规定的‘新发生的费用’，是指 用人单位参加工伤保险前发生工伤的职工，在参加工伤保险后新发生的费用。其中由工伤保险基金支付的费用，按 不同情况予以处理：

（一）因工受伤的，支付参保后新发生的工伤医疗费、工伤 康复费、住院伙食补助费、统筹地区以外就医交通食宿 费、辅助器具配置费、生活护理费、一级至四级伤残职工伤残津贴，以及参保后解除劳动合同时的一次性工伤医疗 补助金；

（二）因工死亡的，支付参保后新发生的符合条件的供养亲 属抚恤金。

劳达解读

要使工伤保险从未参保状态到产生保障作用的过程，大致可以分为三个步骤：办理工伤保险登记—缴纳工伤保险费及滞纳金—工伤保险关系成立。

建立用工关系后，在办理工伤保险登记前发生工伤的，一般依据《工伤保险条例》第六十二条第二款，由用人单位承担工伤保险赔付责任。

工伤已经发生后，用人单位才参加工伤保险并补缴工伤保险费和滞纳金的，是本条适用的情形（《工伤保险条例》第六十二条第三款），区分了用人单位和工伤保险基金的责任负担，并对工伤保险基金在工伤保险关系成立后的新费用做出了界定。这对企业和职工来说是一个利好，同时也鼓励用人单位积极参保，防范工伤保险风险。

还有一个需要注意的问题是：因部分地区（例如武汉市）规定工伤保险关系当月缴费次月才生效的问题，因此用人单位在缴纳工伤保险费（滞纳金）至工伤保险关系成立，有一个空档期。对在这一空档期发生工伤后工伤保险基金是否仍然应该承担法定的保障责任问题，当前的法律并未明确规定。

根据笔者办理过的一个武汉市的劳动争议个案进行说明：该劳动者是在1月17日与用人单位签订了书面的《劳动合同》，该《劳动合同》约定：合同生效日期从2月1日起算。用人单位在1月20日为其办理了工伤保险登记并缴纳了工伤保险费。从1月17日至1月31日期间，用人单位未安排该劳动者上班。后来该劳动者在1月25日发生“非本人承担主要以上责任的交通事故”主张属于工伤，提出劳动仲裁要求用人单位承担工伤保险责任。经汉口区劳动争议仲裁委员会审理后裁决、汉口区人民法院及武汉市中级人民法院审理，均驳回了该员工的诉求。从这个个案我们可以得到启示：在遇到部分地区（例如武汉市）规定工伤保险关系当月缴费次月才生效的情况时，尽管相关法律未能明确“空档期”发生伤害事故的法律责任承担问题，用人单位若处置得当，相关法律风险还是可以避免的。

4 职工在参加用人单位组织或者受用人单位指派参加其他单位组织的活动中受到事故伤害的，应当视为工作原因，但 参加与工作无关的活动除外。

劳达解读

在2014年6月18日《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释（2014）9号）出台以前，关于职工在参加用人单位组织或受单位指派参加其他单

位组织的活动中受到的事故伤害能否认定为工伤的问题，在司法实践中，是存在有很大争议的，比如：员工在用人单位组织的娱乐体育活动或外出旅游过程中受到的事故伤害等，是否属于工伤问题，社保管理部门和人民法院的意见往往存在很大出入。笔者担任咨询顾问的客户单位就遇到一个典型的个案：劳动者王某，在2008年9月12日至14日参加单位组织到福建三清山旅游期间，扭伤脚部。王某所在公司向深圳市劳动和社会保障局申请工伤认定，深圳市劳动和社会保障局于2008年10月29日做出“深劳社认字2008第412836001号《工伤认定书》”认为不属于工伤。王某不服，于2008年11月25日申请行政复议，行政复议机关维持了深圳市劳动和社会保障局做出的不认定为工伤的决定。王某再不服，向深圳市福田区人民法院提起行政诉讼，深圳市福田区人民法院认为“用人单位组织的旅游活动，是单位激励员工工作的一种特殊方式，也是提高工作绩效的有机组成部分，本案原告在单位组织的旅游活动中受伤，应属于因工外出受伤的情形”，因此做出“2009深福法行初字第61号《行政判决书》”撤销深圳市劳动和社会保障局于2008年10月29日做出“深劳社认字2008第412836001号《工伤认定书》”，并责令在本判决书生效之日起十五日内重新做出具体行政行为。之后，深圳市劳动和社会保障局不服一审判决，向深圳市中级人民法院提出上诉。深圳市中级人民法院于2009年11月19日做出终审判决书（2009深中法行终字第236号），判决驳回深圳市劳动和社会保障局的上诉请求，维持原判。

《若干问题的意见（二）》的上述条款，基本上与《[最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定](#)》（法释〔2014〕9号）第四条第一款第二项的规定一致

（（二）职工参加用人单位组织或者受用人单位指派参加其他单位组织的活动受到伤害的）。但有一个除外规定“但参加与工作无关的活动除外”，对于何为与工作无关的活动，就并未做出具体列举进行界定，这也为今后的争议留下了伏笔。在此，劳达顾问提醒各位用人单位注意，在今后组织活动或指派员工参加其他单位组织的活动的，需要在事先、过程及事后注意从多个角度搜集保存“参加与工作无关的活动”的证据。

5 职工因工作原因驻外，有固定的住所、有明确的作息时间，工伤认定时按照在驻在地当地正常工作的处理。

劳达解读

工伤保险一般是采用统筹地管理原则，但实务中因职工驻外工作，造成统筹地和工作地不一致，同时也造成工伤保险参加地和工伤保险发生地不一致。按照本条的规定，驻外职工符合规定的应当按照驻在地标准享受工伤保险待遇，但待遇中工伤保险基金支付部分由参加工伤保险所在地支付。

根据《[劳动合同法实施条例](#)》[第十四条](#)规定：劳动合同履行地与用人单位注册地不一致的，有关劳动者的最低工资标准、劳动保护、劳动条件、职业危害防护和本地区上年度职工月平均工资标准等事项，按照劳动合同履行地的有关规定执行；用人单位注册地的有

关标准高于劳动合同履行地的有关标准，且用人单位与劳动者约定按照用人单位注册地的有关规定执行的，从其约定。

在《若干问题的意见（二）》的上述条款出现之前，在实践中，参加社保统筹地区的社保管理部门往往是无论工伤发生在何地，均一律按照参保地的相关标准计算赔付标准的。相信随着相关社保法律法规和司法解释的进一步实践，还将有进一步的文件出台进行具体操作细则的规范。

笔者认为，相对于《若干问题的意见（二）》第七条的规定而言，本条的遗憾之处是未对驻外职工工伤事故认定、劳动功能障碍等级认定的管理部门做出明确说明。

6 职工以上下班为目的、在合理时间内往返于工作单位和居住地之间的合理路线，视为上下班途中。

劳达解读

本条类似于对《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释〔2014〕9号）第六条的总结，但规定比较概括，实务操作性不强。这或许可以理解为人社部自己发出文件对于最高法院司法解释予以呼应。

7 用人单位注册地与生产经营地不在同一统筹地区的，原则上应在注册地为职工参加工伤保险；未在注册地参加工伤保险的职工，可由用人单位在生产经营地为其参加工伤保险。

劳务派遣单位跨地区派遣劳动者，应根据《劳务派遣暂行规定》参加工伤保险。建筑施工企业按项目参保的，应在施工项目所在地参加工伤保险。

职工受到事故伤害或者患职业病后，在参保地进行工伤认定、劳动能力鉴定，并按照参保地的规定依法享受工伤保险待遇；未参加工伤保险的职工，应当在生产经营地进行工伤认定、劳动能力鉴定，并按照生产经营地的规定依法由用人单位支付工伤保险待遇。

劳达解读

本条涉及工伤保险的统筹地域管理。由于目前我国尚未实行工伤保险全国统筹，多数地区是省级统筹或者市级统筹。在用人单位注册地与生产经营地跨越省级统筹时，有可能出现扯皮推诿的情况。

本条第一项“未在注册地参加工伤保险的，可在生产经营地参加工伤保险”，需要注意的是，依据《[社会保险登记管理暂行办法](#)》[第六条](#)规定：“社会保险登记实行属地管理。如用人单位在统筹地区以外无分支机构，则其社会保险登记地由相关地区协商确定，意见不一致时，由上一级社会保险经办机构确定登记地”。本条直接规定为“由生产经营地”参加工伤保险，显然是对《[暂行办法](#)》修订。在实践中，各地的社保管理部门往往会拒绝在外地注册的用人单位以自己的名义在本地参加社会保险。今后该如何具体实施，需要在后续的修法中予以明确。

跨地区劳务派遣的，依据《[劳务派遣暂行规定](#)》[第十八条](#)、[第十九条](#)处理。

建筑施工企业主要依据《[关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见](#)》（人社部发〔2014〕103号）意见处理，本条明确了工伤保险的管理地即“施工项目所在地”。不过需要注意，跨统筹地区的建筑企业，在统筹地区以外一般是以项目部的名义施工，项目部是否能作为独立的缴费主体，值得考虑。

最后一款是针对跨区域工伤事故提出的管辖权解决方案，对参保地和生产经营地在工伤认定和劳动能力鉴定方面的不同管辖权，区分的依据以是否参加工伤保险为准。这一规定对于指导各地社保管理部门的实践工作有显著的意义。

8 有下列情形之一的，被延误的时间不计算在工伤认定申请时限内。

- （一）受不可抗力影响的；
- （二）职工由于被国家机关依法采取强制措施等人身自由受到限制不能申请工伤认定的；
- （三）申请人正式提交了工伤认定申请，但因社会保险机构未登记或者材料遗失等原因造成申请超时限的；
- （四）当事人就确认劳动关系申请劳动仲裁或提起民事诉讼的；
- （五）其他符合法律法规规定的情形。

劳达解读

本条与《[最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定](#)》（法释〔2014〕9号）第七条阐述问题的角度有一定差别。本条是站在申请人（包含了劳动者和用人单位两方面身份）的角度进行阐述，但总体上为重复。不过遗憾的是无论延误的原因从哪个角度进行表述，均未能解决实践中常见的一种延误现象：即受伤害的劳动者出于各种原因（包括且不限于对法律的误解、幻想多拿赔偿等等），先是不知道或不愿意配合申请工伤认定，在超过法定的30日申报期后又反悔，再要求以自己的名义申请工伤认定的情形。

笔者曾经接受客户单位咨询的一个个案情况是：某用人单位的单位注册地与员工的实际用工地不一致，单位将员工的社保集体安排在单位注册地参保。后来一名在外地工作的员工，发生一起可认定为工伤的交通事故后，造成交通事故的车辆方（第三人）表示愿意积极赔偿该劳动者的所有损失，但需要一个多月时间筹钱。在这种情况下，该劳动者就觉得，与其“费时费力”的配合单位在“外地”办理工伤认定等手续，还不如就近与向肇事车辆方索赔。并且该劳动者认为：能够证明自己遭受身体伤害的各种票据只有一份，若交给单位办理工伤认定申请耗时较长，不利于就近向车辆方出示；并且该劳动者幻想在拿到车辆方的赔偿后，再使用同一份原始单据和证明材料通过单位申报工伤，“再拿一份医疗费赔偿”。

根据《[工伤保险条例](#)》第十七规定：“职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长”。

结果在这种情况下，虽然用人单位努力向社保管理部门申请延期工伤认定，但最终未获批准；而该劳动者打定自己的“如意算盘”后拒绝与用人单位沟通，拒绝进行配合。该劳动者在向车辆方追索赔偿遇阻后，又提出要求单位申请工伤认定。最终因拖延提交资料，导致用人单位无法在规定的期限内完成工伤认定申请而发生工伤待遇劳动仲裁，导致单位遭受重大经济损失。

还有一种现象是：员工在遭受事故伤害后，自己认为不属于工伤，因此没有告知用人单位。结果在超出法定的 30 日申报期后，员工从其他渠道得知本可以获得工伤赔付的情况，遂以自己名义申请工伤认定。最终导致单位遭受重大经济损失。

因此笔者认为：本条关于延误的时间不计算在工伤认定申请时限内的情形尚有可列举的余地，希望相关部门在今后的修法活动中予以补充。

9 《工伤保险条例》第六十七条规定的‘尚未完成工伤认定’的，是指在《工伤保险条例》施行前遭受事故伤害或被诊断为职业病，且在工伤认定申请法定时限内（从《工伤保险条例》施行之日起算）提出工伤认定申请，尚未做出工伤认定的情形。

劳达解读

本条是关于新旧法律的衔接问题，《工伤保险条例》已经实行十余年，本条规定的意义不大，仅仅适用于老工伤人员的待遇争议。

10 因工伤认定申请人或者用人单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料，导致工伤认定决定错误的，社会保险行政部门发现后，应当及时予以更正。

本意见自发文之日起执行，此前有关规定与本意见不一致的，按本意见执行。执行中有重大问题，请及时报告我部。

劳达解读

本条规定与《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》（法释〔2014〕9号）第九条有重复。

依据《工伤认定办法》第二十三条“职工或者其近亲属、用人单位对不予受理决定不服或者对工伤认定决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼”，以往对工伤认定决定错误的救济是赋予当事人行政复议或行政诉讼权利。这一条款赋予社保行政部门自行更正的权利，不过需要注意社保行政部门的更正与工伤保险待遇纠纷仲裁、审理之间的衔接。

谢严兴（劳达集团）

高级咨询顾问、高级合伙人、人力资源管理师

劳达集团

劳达集团(Laboroot)成立于2005年，由知名劳动法与员工关系专家魏浩征先生创办并领衔，是中国第一家专注为雇主方提供劳动法与员工关系咨询、培训及法律服务的咨询公司、律师事务所。

劳达集团(Laboroot)一直致力于综合运用中国本土的劳动法规政策,解决企业人力资源管理过程中的员工关系问题,帮助企业降低人力成本,控制法律风险,实现卓越员工关系管理。

劳达(Laboroot)拥有一支顶尖的专职人力资源咨询顾问与劳动法律师服务团队,九年以上的劳动法与员工关系服务经验,超过 1000 家企业的成功案例。

劳达集团(Laboroot)旗下拥有包括管理咨询公司、人力资源公司、律师事务所等三大业务实体,为各个行业的大中型企业和优质成长型企业提供劳动法与员工关系咨询、法律顾问、培训、劳动争议处理、员工关系外包等专业化、高效率、多层次的人力资源法律服务,业务延伸至管理咨询、服务外包、劳动法及公司法务、互联网、出版等领域。

未经许可,不得转载。



扫一扫,手机阅读更方便